

1500264-78.2019.8.26.0356

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Íris Daiani Paganini dos Santos Salvador

Comarca: Mirandópolis

Foro: Foro de Mirandópolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... que será aplicada a pena atinente ao tráfico de drogas, em conformidade com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista entendimento acerca da inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273, § 1º-B, aplicando-lhe, portanto, a pena do delito de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirandópolis

Foro de Mirandópolis

2ª Vara

Rua Adelino Minari, 726, Mirandópolis - SP - cep 16800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500264-78.2019.8.26.0356 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500264-78.2019.8.26.0356

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIELA LIMA DE JESUS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Iris Daiani Paganini Dos Santos

Vistos.

O Ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de GABRIELA LIMA DE JESUS, qualificada nos autos, por haver, segundo consta, praticado as condutas delituosas tipificadas nos artigos 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/2006 e no artigo 273, §1º-B, inciso I, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, devidamente descrita na inicial acusatória de fls. 118/119.

A acusada foi presa em flagrante no dia 17.03.2019. Em audiência de custódia foi concedida a liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares (fls. 31/33).

Seguindo o procedimento especial previsto na Lei nº. 11.343/2006, a ré foi devidamente notificada (fls. 149) e apresentou defesa preliminar (fls. 38/139).

Na sequência, a denúncia foi recebida em 03.12.2019 (fls. 151) e a ré foi citada (fls. 181).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas da acusação (fls. 186 e 187), uma testemunha exclusiva da defesa (fls. 298), uma informante (fls. 297) e a acusada foi interrogada (fls. 299/300).

Encerrou-se a instrução, tendo as partes apresentado suas alegações finais. O Ministério Público pugnou pela procedência da ação, condenando-se a acusada nos exatos termos da denúncia (fls. 308/314). A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição da acusada, sustentando em relação ao delito do artigo 273 1º-B, inciso I, que a conduta praticada não constitui infração penal e, em relação ao delito do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/2006, que ela teria sido aliciada para que adentrasse a unidade prisional com os ilícitos. Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da lei 11.343/06, bem como a fixação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Pugnou ainda, pela fixação do regime aberto para cumprimento de pena, bem como a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (fls. 319/322).

É o relatório. Fundamento e decido.

A ré foi denunciada porque, segundo consta, no dia 17.03.2019, por volta das 09h, na Penitenciária Nestor Canoa, situada na Avenida Osvaldo Brandi de Faria, nº 4450, no município e comarca de Mirandópolis trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, um invólucro de maconha com peso líquido de 109,33g, substância entorpecente que causa dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta ainda, que nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritas, tinha em depósito para distribuir e entregar a consumo de terceiros medicamentos sem o necessário registro e fiscalização pelo órgão de vigilância sanitária competente.

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado o fato delituoso descrito na denúncia, como se demonstrará a seguir.

A materialidade delitiva é indubitosa, porquanto demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), pelo laudo de constatação preliminar (fls. 10/11), pelo exame químico-toxicológico definitivo (fls. 69/72, 73/75, 76/79, 110/113), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

No tocante a autoria dos fatos também está sobejamente comprovada porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais, no sentido de lhe apontar como autora do crime em apreço.

Vejamos.

Em juízo, a testemunha EDUARDO DA SILVA MARQUES narrou que no dia dos fatos era o plantonista na polícia civil e o agente penitenciário REYNALDO chegou conduzindo a acusada, afirmando que ao passar os alimentos no dela raio-x lograram êxito em encontrar 160 comprimidos de pramil e 110g de maconha (fls. 186).

A testemunha REYNALDO SELLER, agente de segurança penitenciária, disse que estava trabalhando no setor de raio-x, fazendo a revista nos pertences dos visitantes. Quando a ré passou os pertences percebeu que havia algo diferente e na revista encontrou 160 comprimidos de pramil e 110g de maconha (fls. 187).

Em juízo, a informante SANDRA REGINA LIRA DE LIMA, mãe da ré, limitou-se em narrar que ela era obrigada a visitar o companheiro na unidade prisional e sofria ameaças dos reclusos para ir às visitas. O relacionamento dela com o companheiro era conturbado, sendo que ela sempre era agredida e ameaçada. Atualmente eles estão

separados (fls. 297).

A testemunha MARIANA SANTOS CAMPOS DE GOES, em juízo, relatou que é vizinha da acusada há cerca de 20 anos. Acompanhou o relacionamento e o nascimento dos filhos dela. O companheiro da ré sempre foi agressivo. Já presenciou a ré machucada em virtude das agressões (fls. 298).

A acusada foi ouvida em duas oportunidades. Na fase administrativa relatou que recebeu a tupperware na praça da Pousada do Paradise, de uma pessoa conhecida com Marceli. A vasilha era para ser entregue a um sentenciado conhecido por Romarinho. Iria receber a quantia de R\$1.000,00 (mil reais) pelo serviço. Afirmou que tinha conhecimento que havia ilícitos na tupperware, porém tentou entrar na unidade porque precisava do dinheiro. Quando foi abordada e o agente questionou se havia drogas, informou que tinha maconha (fls. 04).

Em juízo, declarou que seu companheiro, à época, era agressivo e queria que fosse visitá-lo de qualquer forma; ele não entendia o alto custo do deslocamento até o estabelecimento prisional e as dificuldades financeiras que suportava. Conheceu pessoas que lhe ofereceram uma quantia em dinheiro para adentrar na unidade com uma tupperware contendo um pouco de maconha e viagra. Não sabe precisar a quantidade. Entregaria para um dos reclusos. Disseram que não poderia mexer na vasilha. Receberia R\$ 1.000,00 (mil reais), caso adentrasse. Seu companheiro não sabia, pois tinha medo de dizer para ele. Aceitou o serviço devido a dificuldades financeiras (fls. 299).

Pois bem, finda a instrução processual, e debruçando-me detidamente sobre a prova colhida em Juízo, estou convencido de que a acusada praticou os crimes que lhe foram imputados.

A acusada confessou a prática criminosa e, em que pese sua confissão não ter mais a força absoluta de outrora, continua sendo importante elemento de prova, ainda mais quando colhida em Juízo, isenta de qualquer coação, e está em consonância com as demais provas carreadas nos autos, que só poderia ser elidida por prova cabal em sentido contrário, o que não ocorreu.

Com efeito, as testemunhas EDUARDO e REYNALDO, nas duas oportunidades em que foram ouvidos, narraram os fatos de maneira firme, coerente e harmônica, descrevendo, detalhadamente, a dinâmica dos fatos, não restando dúvidas de que a acusada tentou adentrar no estabelecimento prisional com o entorpecente e medicamento. Tal versão foi corroborada pela própria ré, que como já ressaltado, confessou de livre e espontânea vontade a prática do delito.

Por outro lado, as testemunhas arroladas pela defesa não trouxeram nenhum argumento que pudesse infirmar as provas colhidas em juízo. Em verdade, vieram em juízo com o nítido intuito de minimizar a responsabilidade criminal da acusada.

Destarte, os elementares do crime descrito no artigo 273, §1º-B, inciso I, do Código Penal, restaram comprovados. A materialidade está bem demonstrada no laudo pericial acostado às fls. 76/79 e 110/113, segundo o qual, as substâncias apreendidas nos autos apresentaram resultados positivos para Citrato de Sildenafil, popularmente conhecido como “viagra”, que não possui registro na ANVISA, sendo proibidos sua importação, comércio e uso em todo o território nacional.

Ademais, no que tange ao delito previsto no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, restou devidamente comprovada pelo local da infração e pela materialidade delitiva pelo exame químico-toxicológico de fls. 69/72, com resultado positivo para maconha, substância entorpecente que causa dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação

legal e regulamentar.

Assim, a responsabilidade criminal da ré é latente, não devendo ser cogitada a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade de seu comportamento; ao contrário, existe potencial dano ao objeto jurídico tutelado pela norma (saúde pública), devendo ser reconhecido o ilícito penal que lhe é imputado, de modo que sua condenação é medida que se impõe.

Bate-se a Defesa técnica na absolvição da acusada, sustentando que a conduta praticada não constitui infração penal, entretanto, a tese aventada não pode prevalecer, por todo o exposto até o momento.

Questões relativas à dosimetria da pena serão analisadas oportunamente.

Portanto, em consideração aos argumentos postos, e não havendo dúvida alguma quanto à autoria do crime, comprovada estreme de dúvida pela prova produzida nesta ação, deve a ré responder pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006 e artigo 273, §1º-B, inciso I, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

Inicialmente, anoto que será aplicada a pena atinente ao tráfico de drogas, em conformidade com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista entendimento acerca da inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273, § 1º-B, aplicando-lhe, portanto, a pena do delito de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da AI no HC n. 239.363/PR, declarou a inconstitucionalidade do preceito secundário da norma prevista no art. 273, § 1º-B, do Código Penal. Ante a referida declaração de inconstitucionalidade, a consequência deve ser a determinação de retorno dos autos à instância a quo, a fim de que proceda à nova capitulação jurídica, atentando-se ao preceito secundário que melhor se adeque ao fato, prejudicadas as demais questões (STJ Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior 6ª Turma AgRg no AREsp nº 959060/RS j. 22/11/2016).

Apurada a responsabilidade do acusado, passo a dosar a pena de condenação, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Conforme F.A. de fls. 121 e certidões de fls.23/124, a ré é primária e não ostenta maus antecedentes. Não há nos autos elementos para se ponderar as demais circunstâncias judiciais, razão pela qual é de rigor a fixação da pena base no mínimo legal cominado, a saber: artigo 273, § 1º-B do Código Penal - 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados no mínimo unitário; 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006 - 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados no mínimo unitário.

Não há agravantes e nem atenuantes. A atenuante da confissão deixa de ser aplicada ante a fixação da pena no mínimo legal.

Na terceira fase de fixação da pena, deve ser aplicada a causa especial de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, uma vez que restou comprovado que o tráfico ocorreu no interior de estabelecimento prisional, razão pela qual majoro a pena em 1/6.

Contudo, aplicável in casu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Conforme se depreende da F.A., a ré é primária e sem antecedentes criminais. Ademais, não há nos autos qualquer indício de que integre

organização criminosa. Fixada a aplicação da causa de diminuição da pena, deve-se dosá-la dentro dos limites legais. Para tanto, devem ser ponderadas as circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal e, precipuamente, o disposto no art. 42 da Lei. 11.343/2006. Com base nesses preceitos, e considerando a análise feita para a fixação da pena base, esta deve ser reduzida em 2/3, passando a reprimenda de: artigo 273, § 1º-B do Código Penal - 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixados no mínimo unitário; 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006 - 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixados no mínimo unitário.

Em observância à regra insculpida no art. 69 do Código Penal aplico as penas cumulativamente: 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (dias) de reclusão e o pagamento de 388 dias-multa, fixados no mínimo unitário.

Inocorrentes outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva.

Com relação à fixação do regime inicial da pena, em sessão extraordinária realizada no dia 27 de junho de 2012, no julgamento do HC n.º 111.840, o Supremo Tribunal Federal declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do parágrafo 1º, do artigo 2º, da Lei n.º 8.072/90. Assim, mesmo se tratando de crimes hediondos e equiparados, a fixação do regime inicial para cumprimento da pena deverá ser feita com observância das normas contidas no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Assim, no caso em tela, fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena, tendo em vista o quanto disposto pelo art.33, §2º, alínea "c" do CP.

Ainda, uma vez que a apenada preenche os requisitos estampados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, substituo-lhe a pena privativa de liberdade ora aplicada por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, em entidade ou programa comunitário ou estatal a ser oportunamente designado, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, nos termos do artigo 46, caput, e §§ do Código Penal e prestação pecuniária, fixada em 01 (um) salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pelo Juízo da execução, nos termos dos artigos 43, inciso I e 45, § 1º, ambos do Código Penal, substituição essa que determino com supedâneo no art. 44, § 2º, segunda parte, do mesmo Código.

Por fim, esclareço que as Cortes Superiores já firmaram o entendimento no sentido da possibilidade de fixação de regime aberto, bem como medidas alternativas à pena privativa de liberdade nos crimes de tráfico de entorpecentes quando os requisitos legais forem preenchidos. Nesse sentido: STF, 2ª T., HC 138160 SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/12/2016, p. 16/12/2016.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o faço para condenar GABRIELA LIMA DE JESUS, como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/2006 e no artigo 273, §1º-B, inciso I, na forma do artigo 69, ambos do Código Pena, aplicando-lhe à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (dias) de reclusão e o pagamento de 388 dias-multa, fixados no mínimo unitário e atualizado consoante preconiza o artigo 49, § 2º, do Código Penal, sendo que elas deverão ser substituídas pelas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade a ser cumprida no mesmo prazo fixado para a pena privativa de liberdade, bem como pela pena pecuniária, da forma retro descrita nesta sentença.

Não se mostram presentes os pressupostos da cautelardade da prisão (artigo 312 do Código de Processo Penal), além do que a pena imposta é incompatível com o regime fechado e à restrição do status libertatis do indivíduo, pelo que fica concedido ao sentenciado o direito de apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado lance-se o nome da condenada no rol dos culpados e expeça-se o mandado de prisão.

Oportunamente, se o caso, expeça-se a certidão de honorários advocatícios ao defensor dativo, no patamar máximo prevista na Tabela do Convênio DPE/OAB.

Custas ex lege.

P.I.C..

Mirandópolis, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA